

1501829-96.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... existência material dos crimes de tráfico e receptação restaram demonstradas nos autos por meio do boletim de ocorrência relativo ao tráfico e a receptação (fls. 34/41), boletim de ocorrência do crime patrimonial antecedente (fls. 21/23), fotografias das drogas apreendidas (fls. 25/36), auto de apreensão dos objetos (celular, 2 placas de automóvel, veículo e droga (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501829-96.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501829-96.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS MARTINS CURSINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual MATEUS MARTINS CURSINO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 106/108) que, no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 10h30min, na Rodovia Rodoanel Mario Covas - Trecho Oeste, na via pública, altura do km 25+200, Santa Maria, nesta cidade e Comarca de Osasco, MATEUS MARTINS CURSINO, qualificado a fls. 07/08, guardava e transportava droga, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para fins de venda para consumo de terceiros, consistente em 10 (dez) fardos contendo 337 (trezentos e trinta e sete) tablets de Cannabis sativa L (maconha), no total de 195,40kg (cento e noventa e cinco quilogramas e quarenta centigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 18/20, fotografias de fls. 25/35 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

Consta, ainda, dos inclusos autos do inquérito policial que, na mesma data, hora e local, MATEUS MARTINS CURSINO, qualificado a fls. 07/08, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo Hyundai/HB20 1.6A, de placas originais FPB 6B77/Itápolis-SP, mas que, na ocasião, ostentava as placas AZM 8C92, a ser

oportunamente avaliado, coisa que sabia ser produto de crime

Segundo se apurou, o veículo Hyundai/HB20 1.6A, de placas FPB 6B77/Itápolis-SP, fora roubado na cidade de Itápolis, em data a ser oportunamente verificada.

Em data incerta, mas entre a data do roubo e o dia 03 de agosto de 2022, o denunciado recebeu, de pessoa não identificada e em circunstâncias não esclarecidas, o mencionado automóvel, agora ostentando as placas AZM 8C92, sabendo de sua origem espúria, visto estar desacompanhado de qualquer documento que lhe garantisse a licitude de sua posse, além de ter, em seu interior, um par de placas automotivas de origem não identificada e com objetivo desconhecido e suspeito.

Na data do acontecido, policiais militares rodoviários realizavam operação de fiscalização de trânsito junto ao pedágio da CCR Rodoanel, situado no sítio dos fatos, quando abordaram o denunciado, oportunidade em que solicitaram a documentação veicular e a carteira de habilitação do condutor, no que o denunciado revelou que não as possuía.

Na ocasião, os policiais sentiram um forte odor de maconha vindo do veículo, ensejando a revista veicular. Promovendo uma busca no interior do automóvel, os policiais localizaram um par de placas automotivas que, em pesquisa, não revelaram ligação com qualquer crime.

Ao abrirem o porta-malas do veículo, os agentes da lei encontraram dez fardos contendo inúmeros tabletes de maconha, evidenciando, pelo volume descomunal, tratar-se de droga para venda para consumo de terceiros.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01/02.

Auto de exibição e apreensão às fls. 14/15.

Laudo de constatação às fls. 18/20.

Fotografia dos entorpecentes apreendidos às fls. 25/36.

Em sede de audiência de custódia (fls. 54/59), a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva. Mandado de prisão cumprido às fls. 93/97.

Em decisão de fls. 110/117, procedeu-se à conversão do rito especial previsto na Lei 11.343/06 para o rito ordinário do Código de Processo Penal e a denúncia foi integralmente recebida.

Laudo químico-toxicológico definitivo juntado às fls. 126/128.

Citado às fls. 132, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da sua Defesa constituída (fls. 134/136).

Em decisão de fls. 137/138, este juízo manteve o recebimento da denúncia, mesma oportunidade em que designou audiência presencial de instrução, debates e julgamento para o dia 06.10.2022, às 14h15.

Folha de antecedentes às fls. 144/145, dando conta de que o réu é primário.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa sendo o réu, ao final, interrogado.

Em memoriais (fls. 165/202) a Acusação pediu a procedência nos termos da inicial.

Em memoriais (203/210) a Defesa pediu o reconhecimento do privilégio.

É relatório.

Fundamento e decido

O pedido é procedente.

A – Valoração probatória de autoria e materialidade

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e do art. 180 “caput” do Código Penal, tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva, como também à comprovação da autoria e da materialidade referente à conduta de transportar drogas destinadas a consumo de terceiros e de conduzir, em proveito próprio ou alheio, o veículo Hyundai/HB20 1.6A, de placas originais FPB 6B77/Itápolis-SP,

A existência material dos crimes de tráfico e receptação restaram demonstradas nos autos por meio do boletim de ocorrência relativo ao tráfico e a receptação (fls. 34/41), boletim de ocorrência do crime patrimonial antecedente (fls. 21/23), fotografias das drogas apreendidas (fls. 25/36), auto de apreensão dos objetos (celular, 2 placas de automóvel, veículo e droga (fls. 14/15) e laudo químico-toxicológico (fls. 126/128).

Quanto à imputação de autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação aos delitos narrados na inicial.

As premissas fáticas de que o réu transportava drogas destinada a terceiras pessoas e que conduzia um veículo ciente de sua origem espúria restaram comprovadas nos autos para além de qualquer dúvida, o que afasta o postulado da presunção de inocência.

O réu, em juízo, confessou os parcialmente os fatos (ao final negou a ciência ilícita do veículo). Afirmou que tinha ciência da droga. O veículo estava com o documento atrasado. Afirmou que não tinha ciência que no veículo se encontravam duas placas. Por conta de dívidas, relatou que estava levando a droga para São Paulo. Pegou o carro com a droga no Estado do Paraná. Estava sendo pago para transportar a droga. Não sabe quem é a pessoa que entregou o carro. Pegou o carro em Ponta Porã. Os dados da pessoa que estava devendo foram passados por celular. A pessoa falou para pegar o carro na estrada perto do posto. Passou o endereço de entrega pelo celular e dirigiu-se a São Paulo seguindo o Wase. Não sabia o lugar em São Paulo para a entrega. Somente fora passada a localização. Quando pegou o carro este estava estacionado com a chave no pneu. A pessoa que tratou pelo celular somente identificou o carro. No momento de pegar o carro não teve contato com ninguém. Iria ganhar 1800 reais pelo transporte. Sua dívida era de 1500 reais. Negou, ao final, que soubesse que o veículo era fruto de roubo. A dívida era com agiota.

A confissão do réu relativa ao crime de tráfico restou comprovada nos autos tanto pela prova oral quanto material. Por outro lado, a negativa do dolo em relação ao crime de receptação restou isolada. Pelo contrário, o contexto fático, ou melhor, os indicadores externos da conduta, permitem concluir que o réu tinha ciência de que conduzia um veículo cuja origem é ilícita.

A testemunha Pablo, em resumo, afirmou que estava com seu parceiro realizando fiscalização veicular na pista externa do rodanel. Ao parar o veículo, seu parceiro “sentiu algo diferente”. No banco de trás havia duas placas veicular. Pediram para abrir o porta-malas e havia centenas (300) de tabletes de maconha.

Tanto as placas encontradas quanto a placa do veículo não constavam ser produto de ilícito, o que somente foi visto pelo chassi. Para seu parceiro o réu relatou que veio com o carro do Paraná. Disse o réu que acompanhava no Waze o local para o qual iria.

A testemunha Carlos, da mesma forma, relatou que realizava operação de fiscalização. Deu sinal de parada. Solicitou a habilitação e documento. O réu não era habilitado e no momento falou que o carro era Bangu (“de procedência ilícita ou somente para rodar sem documentação”). Havia cheiro de “maconha”. Em busca localizou a maconha em tabletes. Levantou o banco e encontrou duas placas de automóvel. Tanto as placas encontradas quanto as do veículo não constava como ilícito. Somente pelo chassi verificou-se que era produto de furto. No momento o réu falou que veio de ônibus e pegou o carro em São Paulo para levar para o litoral.

Inicialmente, anoto que não há porquê se duvidar da versão do policial. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é por que a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com os demais elementos de prova. No caso dos autos, não há contrariedade capaz de infirmar a prova nas versões das testemunhas, pois as duas testemunhas confirmaram a apreensão da droga no porta-malas além das duas placas.

Valorando-se racionalmente a prova oral verifica-se que está confirmada a autoria da conduta típica imputada da inicial de transportar drogas, o que se amolda ao tipo do art. 33 da Lei 11.343/06. Da mesma forma, não há dúvida quanto ao elemento subjetivo, ou seja, a consciência e vontade transportar o entorpecente destinado a consumo de terceiro, seja pela quantidade, seja pela forma como estavam acondicionados e pelo local, qual seja, dentro do porta-malas de um veículo o qual o réu, segundo afirma, encontrou estacionado com as chaves do pneu preparado para o transporte. Não há dúvidas, por fim, que as drogas eram voltadas ao comércio espúrio.

Por outro lado, mesmo tendo negado a ciência da origem do veículo, o fato de afirmar para os policiais que o carro era “bangu”, de ter pego o automóvel já preparado, de pessoa cuja indicação recebeu por celular e, ainda, havendo no seu interior duas placas de automóvel, além de não possuir habilitação ou documentação, são indicativos objetivos externos suficientes para comprovação do injusto em sua dimensão subjetiva.

Por fim, além dos tipos objetivos, também restou demonstrada a causa de aumento de pena do art. 40, inc. V referente a interestadualidade pois, não apenas pela confissão, mas pelo que relatado pelos policiais, a droga apreendida no rodão - Estado de São Paulo - fora recolhida no Estado do Paraná, especificamente em Ponta-Porã.

Portanto, superado o postulado da presunção de inocência, legítima é a condenação com consequente imposição de pena, eis que reconhecida a responsabilidade penal.

B – Redutor de pena

Dispõe o art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06: § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A lei estabeleceu 4 critérios para verificação do merecimento ou não do redutor de

pena. Dois critérios afirmativos e dois negativos. Quanto aos afirmativos o réu deve ser primário, cuja verificação técnica se dá na forma do art. 64 do Código Penal e ser portador de bons antecedentes (sem condenação não apta a gerar reincidência). Por outro lado, quanto aos critérios negativos, o réu não pode se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Relativamente às atividades criminosas, depreende-se que o legislador exige uma relativa habitualidade, uma reiteração de condutas, o que deve ser extraído dos elementos probatórios disponíveis nos autos. No caso em tela, além da confissão do réu que justificou ter aceitado trazer as drogas até São Paulo – não há elemento de prova que demonstre que ele se dedique, de forma pressuposta e duradoura, a atividades criminosas ligadas ao tráfico, até porque, segundo colhe-se dos autos, e da própria confissão, o réu aceitou realizar o transporte porque possuía uma dívida com agiota e nada indica que esteja imiscuído no universo do tráfico de entorpecentes. Funcionou no caso concreto o réu ao fazer o transporte como “mula”. Este requisito poderia restar demonstrado caso tivesse havido maiores investigações pela autoridade judiciária, o que não ocorreu no caso em apreço, tanto que dos autos verifica-se haver um celular apreendido, não tendo sido requerida pela autoridade policial qualquer diligência de investigação.

Anoto que a quantidade de drogas, por si só, sem outras investigações da polícia judiciária, não permite a conclusão de dedicação do réu à atividade ligada ao tráfico. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele “não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas”. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 148579 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

Por fim, a lei estabelece que não tem direito ao redutor o sujeito que integrar organização criminosa. Ora, com mais razão este critério negativo deve ser afastado. Integrar significa fazer parte ou pertencer a organização criminosa. Entretanto, a conduta de integrar exige a verificação de uma questão pressuposta, qual seja: que exista uma organização criminosa. A Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, §1º, após muito debate doutrinário e jurisprudencial e influenciada, é verdade, pela Convenção de Palermo, estabeleceu um conceito de organização criminosa, segundo o qual: “§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A demonstração dos requisitos do conceito legal, em primeiro lugar, exige investigação por parte das agências de persecução, o que não há no caso em tela.

Em segundo lugar, a partir da própria tipificação legal, exigem-se os seguintes requisitos objetivos para a configuração da organização criminosa: (i) a presença de 4 (quatro) ou mais pessoas; (ii) a verificação de uma estrutura ordenada; (iii) a divisão de tarefas entre os indivíduos componentes da referida estrutura, ainda que de maneira informal; (iv) a finalidade de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagem de qualquer natureza; e (v) a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional,

a fim de obter as vantagens em questão.

Assim, observa-se que a organização criminosa tem características próprias e específicas, demandando a verificação in concreto dos cinco requisitos supramencionados para a sua caracterização e consequente justificação do acréscimo de pena. Necessário, portanto, elementos mínimos que demonstrem os cinco requisitos até para que se não banalize esta figura jurídica.

No caso dos autos, não há absolutamente qualquer elemento que demonstre que o réu integre organização criminosa.

C - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena.

Tendo em vista o concurso material de delitos, eis que o réu praticou mais de uma ação, inicialmente, passo a aplicar a pena pelo crime do art. 33 da lei 11.343/06

Com relação ao crime do art. 33, "caput" da Lei n. 11.342/06:

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, em especial a expressiva quantidade de droga (163,940 kg) fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, aumentando-a em 3 anos, perfazendo 8 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STF - HC nº 91.487/RO. 1ª Turma. Rel. Min. Carmen Lúcia.j 11/09/2007, AgRec no HC - n. 181.632-PR - Rel. Min. Roberto Barroso e STJ - AgRg no HC 590.270/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020).

Na segunda fase, diante da confissão espontânea quanto ao tráfico, reduzo a pena em 1/6, o que perfaz 6 anos e 8 meses de reclusão e 500 dias multa.

Na terceira fase, verifico a incidência do art. 40, inc. V, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, o que perfaz 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 583 dias multa.

Ainda na terceira fase, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, perfazendo 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 194 dias multa.

Com relação ao crime do art. 180 "caput" do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente pelo fato do réu ser primário e não ostentar antecedentes, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Aplicando-se a regra do concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal), em relação às duas condutas, a pena total do réu permanecerá, em definitivo, em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias multa

Em que pese a quantidade objetiva de pena fixada ao final, a quantidade de droga transportada importa maior juízo de censura, e, assim, o réu não faz jus a substituição por pena restritiva na medida em que, sendo maior o merecimento de

pena decorrente da culpabilidade, a substituição não se mostra suficiente ao desiderato da pena que deve ter o sentido contra-fático de restabelecimento do direito e orientada a prevenção geral e especial.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto pois, como mencionado, a culpabilidade no sentido de reprovação pela conduta, modulada pela expressiva quantidade de droga, não indica que o regime aberto seja suficiente para os fins da pena.

O réu está preso desde agosto de 2022. O tempo de prisão provisória não altera o regime fixado tendo em vista a argumentação exposta.

D- Do dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal e:

CONDENO MATEUS MARTINS CURSINO, qualificado nos autos, ao cumprimento de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 204 dias-multa no valor mínimo, com atualização desde o trânsito em julgado, por infração artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e artigo 180, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.

E - Demais deliberações

Considerando o regime de pena inicialmente fixado, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade diante da incompatibilidade do regime intermediário com a custódia cautelar. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (STF – HC. 186.648 – Min. Cármen Lúcia – j. 08.06.2020). Também: HABEAS CORPUS n. 204.618 – SC – Min. Alexandre de Moraes – j. 19.07.2021). também: HC n. 213.750, Rel. Min. Ministro Edson Fachin, DJe 05.04.2022.

Ainda, anoto a atual recomendação do CNJ a qual determina a expedição de guia de recolhimento sem a necessidade de expedição de mandado de prisão. Assim, por mais esse argumento, a fixação de regime semiaberto se mostra incompatível com custódia cautelar (Resolução 474 do CNJ e Comunicado CG nº 628/2022 – CPA 2021/104300).

Assim, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

i) Expeça-se guia de execução, encaminhando-se, em seguida, à Vara das Execuções Criminais competente.

ii) Ainda, (i) certifique-se acerca de eventual valor de fiança recolhido nos autos, (ii) elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e (iii) realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ. Por fim, (iv) intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no art. 479-B das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao

Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

iii) Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

iv) Também determino a perda do veículo em favor do Estado, sendo autorizado desde já o leilão, eis que se trata de instrumento para a prática do injusto penal de transportar drogas. Oficie-se.

v) Quanto ao celular, determino a destruição. Oficie-se.

vi) No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 24 de outubro de 2022.